

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제1절 증거의 총설>

I. 증거의 의의

1. 개념

- 증거란 재판에서 사실인정의 근거가 되는 자료를 의미한다. 민사소송에서 법원은 당사자 사이에 다툼이 있는 사실에 대하여 판단을 내려야 하며, 이때 판단의 기초가 되는 지식이나 자료를 증거라고 한다. 증거는 넓은 의미에서 증거방법과 증거자료, 증거원인을 모두 포괄하는 개념이다. 증거방법은 법원이 그 내용을 조사하기 위하여 대하는 유체물을 의미하며, 증인·감정인·문서·검증물 등이 이에 해당한다. 증거자료는 증거방법을 조사하여 얻은 내용, 즉 증인의 증언이나 감정 결과 등을 뜻한다. 증거원인은 법원이 증거조사를 통해 얻은 확신이나 심증을 말한다.

2. 필요성

- 재판은 법적 효과를 발생시키는 요건사실의 존부를 확정하는 과정이다. 당사자가 주장하는 사실에 대하여 상대방이 다투지 않는 경우에는 증거가 필요 없으나, 사실관계에 관하여 다툼이 있는 경우에는 법관이 객관적인 근거 없이 판결을 내릴 수 없다. 따라서 법관이 합리적인 확신을 가지고 사실을 인정하기 위해서는 증거가 반드시 필요하다. 이는 자의적인 재판을 방지하고 판결의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위한 법치주의적 요청이기도 하다. 만약 증거에 의하여 사실이 확정되지 않는다면 법원은 입증책임의 원칙에 따라 판결할 수밖에 없으므로, 당사자 입장에서 자신의 주장을 관철하기 위해 증거 제시는 필수적이다.

II. 증거능력과 증거력

1. 증거능력

- 증거능력이란 특정 증거방법이 법정 증거조사 절차에 사용될 수 있는 법률상 자격을 의미한다. 민사소송법은 형사소송법과 달리 자유심증주의를 채택하고 있으므로 증거능력에 대한 제한이 매우 완화되어 있다. 즉, 원칙적으로 모든 증거방법은 증거능력이 인정된다. 다만, 신의칙에 반하여 위법하게 수집된 증거의 경우 그 증거능력이 부정될 수 있다는 논의가 존재한다. 예를 들어 도청이나 비밀 녹취와 같은 위법 수집 증거에 대해 판례는 그 증거능력을 원칙적으로 인정하면서도, 인격권 침해의 정도와 진실 발견이라는 공익을 비교衡量하여 개별적으로 판단하고 있다.

2. 증거력

- 증거력이란 법관이 증거조사를 마친 후 그 증거자료를 통해 사실의 존부에 대하여 얻게 된 확신의 정도, 즉 증거의 실질적 가치를 의미한다. 이를 증거의 가치 또는 신빙성이라고도 한다. 증거력의 판단은 전적으로 법관의 자유로운 판단에 맡겨져 있으며, 이를 자유심증주의라고 한다. 법관은 증인이나 문서의 내용을 종합적으로 검토하여 어느 정도의 무게를 둘 것인지를 결정한다. 증거능력이 증거가 법정에 들어올 수 있는 문턱이라면, 증거력은 그 문턱을 넘은 증거가 판결에 얼마나 영향을 미치는가의 문제이다.

III. 증거의 종류

1. 본증과 반증

- 본증은 입증책임을 지는 당사자가 자기의 주장사실을 확정하기 위해 제출하는 증거를 의미한다. 반면, 반증은 본증에 의해 인정되는 사실을 부정하기 위하여 상대방이 제출하는 증거를 말한다. 본증은 법관으로 하여금 확신을 갖게 해야 하지만, 반증은 본증에 의한 법관의 확신을 흔들어 불명의 상태로 만드는 것만으로도 그 목적을 달성한다. 즉, 반증은 본증이 주장하는 사실이 진실이 아닐지도 모른다는 의심을 불러일으키는 것만으로 충분하다.

2. 직접증거와 간접증거

- 직접증거는 요건사실인 주된 사실의 존부를 직접 증명하는 증거를 의미한다. 예를 들어 계약의 성립 여부가 쟁점일 때 해당 계약서나 계약 체결을 직접 목격한 증인의 증언이 이에 해당한다. 간접증거는 요건사실을 직접 증명하지는 않지만, 요건사실의 존부를 추인하게 하는 사실(간접사실)을 증명하는 증거를 말한다. 대여금 소송에서 차용증은 없으나 돈을 송금한 영수증이나 돈을 빌려달라고 요청했던 문자 메시지 등은 간접증거가 된다. 현대 소송에서는 직접증거가 없는 경우가 많으므로 여러 간접증거를 종합하여 사실을 추론하는 방식이 빈번하게 사용된다.

IV. 증명과 소명

1. 증명

- 증명이란 법관이 사실의 존부에 관하여 확신을 얻은 상태, 또는 그러한 상태에 이르도록 증거를 제시하는 활동을 의미한다. 민사재판에서 증명은 고도의 개연성을 필요로 한다. 즉, 통상적인 사람이 의심을 품지 않을 정도의 확신이 있어야 사실로 인정된다. 만약 법관이 확신에 이르지 못하고 진위 불명의 상태에 머문다면 입증책임의 분배 원칙에 따라 해당 사실이 없는 것으로 간주되어 판결이 내려진다.

2. 소명

- 소명이란 증명보다 낮은 단계의 확신을 의미한다. 즉, 법관이 일단 그럴 것이라고 추측할 수 있는 정도의 상태를 말한다. 소명은 주로 신속성을 요하는 가압류, 가처분과 같은 결정 절차나 소송절차상의 부수적 사항을 신청할 때 요구된다. 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거방법에 한정되는 것이 원칙이며, 증명에 비해 입증의 정도가 완화되어 있다. 법률에서 '소명하여야 한다'고 규정한 경우에는 증명에 준하는 엄격한 확신까지는 필요하지 않다.

V. 결론

- 증거는 재판의 승패를 결정짓는 가장 핵심적인 요소로서, 법치주의에 입각한 공정한 사실확정의 토대가 된다. 증거능력의 개방성과 증거력의 자유로운 심증 형성을 특징으로 하는 현대 민사소송법은 법관의 합리적인 재량을 존중하면서도, 본증과 반증의 대립 및 직접·간접증거의 조화를 통해 실체적 진실에 다가가고자 한다. 당사자는 자신이 주장하는 바에 따라 증명과 소명의 단계를 명확히 구분하여 적절한 증거방법을 제시해야 하며, 법원은 제출된 증거자료를 신중히 검토하여 정의로운 판결을 내려야 한다. 결국 증거법의 원리는 절차적 정당성을 유지하면서도 구체적 타당성을 확보하기 위한 법적 장치로서 그 의의를 지닌다.